

刑法
No166

共通問題 H28-3

(配点：2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記1から5までの各記述のうち、甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論拠となり得ないものはどれか。

【事例】

甲は、乙又は乙の友人が窃盗罪を犯そうとしていることを知り、その手助けのため、乙に対し、同罪の遂行に必要な道具を貸したところ、さらに、乙はその道具を友人丙に貸し、丙がこれを用いて同罪を犯した。なお、丙には同罪の正犯が成立し、乙にはその従犯が成立するものとする。

1. 従犯には独立した犯罪性が認められる。
2. 従犯の幫助には、教唆者を教唆した者については正犯の刑を科すとする刑法第61条第2項のような規定がない。
3. 共犯は修正された構成要件に該当する行為であるところ、従犯もその構成要件においては「正犯」となる。
4. 幫助は正犯を容易にすることであるという定義からすると、幫助行為が直接的になされたか、間接的になされたかは必ずしも問われない。
5. 教唆犯に対する幫助行為は従犯として処罰される。

1 論拠となり得る

【事例】において、乙は、窃盗罪の正犯たる丙を幫助した従犯であるが、従犯乙を幫助した甲に、従犯が成立するか、といういわゆる間接幫助の成否が問題となる。幫助を共犯としての実行行為と考え、従犯にも独立した犯罪性を認めたならば、間接幫助も、幫助という犯罪行為を幫助した者として62条1項により可罰的となる。よって、従犯には独立した犯罪性が認められるということは、間接幫助を肯定する論拠となり得る。したがって、本記述は甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論拠となり得る。

2 論拠となり得ない

間接教唆は61条2項で教唆とされるが、間接幫助の規定は存在しない。そうすると、共犯の処罰もなんらかの意味で正犯行為を前提とするという従属性説に立脚する場合、幫助は実行行為ではなく、幫助を幫助した者は62条1項の「正犯を幫助した者」にはなり得ないと説明できる。よって、従犯の幫助には、教唆者を教唆した者については正犯の刑を科すとする61条2項のような規定がないことは、間接幫助を否定する論拠であり、間接幫助を肯定する論拠となり得ない。したがって、本記述は甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論拠となり得ない。

3 論拠となり得る

共犯行為も犯罪である以上、構成要件に該当するものでなければならない。その構成要件は、刑法各本条と60～63条との結合によって生まれる共犯構成要件である。そうであれば、そこには共犯としての実行行為を觀念することが可能である。そうすると、幫助のような修正された構成要件である実行行為を行った者（本問における乙）も「正犯」に当たるので、間接幫助（本問における甲）も「正犯」を幫助した者として、62条1項により可罰的となる。よって、共犯は修正された構成要件に該当する行為であるところ、従犯もその構成要件においては「正犯」となることは、間接幫助を肯定する論拠となり得る。したがって、本記述は甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論拠となり得る。

4 論拠となり得る

幫助犯の処罰根拠は正犯の実行行為を容易にすることにあるから、直接に正犯の実行行為を容易にする直接幫助ばかりでなく、間接に容易にする間接幫助も幫助犯になり、理論的には連鎖的教唆の可罰性と異ならない。すると、間接幫助犯（本問における甲）は、実行行為を行った「正犯」（本問における丙）を幫助したといえ、62条1項により可罰的となる。よって、幫助は正犯を容易にすることであるという定義からすると、幫助行為が直接的になされたか、間接的になされたかは必ずしも問われないことは、間接幫助を肯定する論拠となり得る。したがって、本記述は甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論拠となり得る。

5 論拠となり得る

教唆の幫助を可罰的とする根拠は、教唆も修正された構成要件に該当する実行行為であるから、このような「実行行為」を幫助した者として62条1項により可罰的となるという点にある。そうすると、幫助行為も修正された構成要件に当たる以上、間接幫助犯（本問における甲）は、「実行行為」を行った「正犯」（本問における乙）を「幫助」した者に当たり、62条1項により可罰的となる。よって、教唆犯に対する幫助行為は従犯として処罰されることは、間接幫助を肯定する論拠となり得る。したがって、本記述は甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論拠となり得る。